

甘露诉暨南大学开除学籍决定行政纠纷再审案——立法原意、学术剽窃与司法审查：“甘露案”判决论理之检讨

案由：	行政 > 行政主体 > 教育行政管理（教育） 行政 > 行政行为 > 行政裁决
文书类型：	判决书
公开类型：	文书公开
审理法院：	最高人民法院
案件类型：	行政再审
审理程序：	再审
权责关键词：	行政许可 合法 违法 基本原则 受案范围 第三人 关联性 合法性 回避 提审 可诉性
来源：	施立栋：《立法原意、学术剽窃与司法审查——“甘露案”判决论理之检讨》，载《行政法论丛》2014年第2(第16卷)期，第309页

甘露诉暨南大学开除学籍决定行政纠纷再审案

——立法原意、学术剽窃与司法审查：“甘露案”判决论理之检讨

一、引言

法院是推动行政法理论发展与规则变迁的重要力量。[1]中国法院在高等教育行政诉讼领域所作的创造性探索，便印证了这一点。自“田永诉北京科技大学案”以来，通过在学位授予、招生决定、纪律处分等领域作出的一系列重要判决，中国法院在推动高校行政诉讼案件受案范围的拓展、行政法基本原则的适用、司法审查标准的反思等方面，展现出了难能可贵的司法能动主义立场。这些创造性的司法实践，不仅有力地推动了中国高校的法治化进程，也促使西方学者开始改变那种认为中国法官一贯消极、素质欠佳的固有偏见。[2]

2012年第7期的《最高人民法院公报》（以下简称《公报》）上刊载的“甘露不服暨南大学开除学籍决定案”（以下简称“甘露案”），是又一个具有里程碑意义的案件。它是最高人民法院审结的首个高校行政诉讼案件。其基本案情是：甘露是暨南大学的硕士研究生。2005年间，其先后两次将从

互联网上抄袭的论文提交给任课教师，作为课程结束时的考核论文。对此，暨南大学于2006年6月对其作出了开除学籍的处分决定。甘露不服，向广州市天河区人民法院提起诉讼。一审法院维持了开除学籍的决定。甘露不服提起上诉后，广州市中级人民法院维持了原判。后来甘露向广东省高级人民法院申请再审，该院驳回了其再审申请。之后甘露向最高人民法院申请再审，后者提审了该案。案件的核心争点在于，甘露在结课论文实施的剽窃行为，是否属于《暨南大学学生管理暂行规定》第53条第5项规定的“剽窃、抄袭他人研究成果”的行为。对此，一审和二审法院均持肯定观点。但最高人民法院在再审中却持否定态度，并因此撤销了之前的生效判决，确认暨南大学作出的开除学籍处分决定违法。

与之前的高校行政诉讼案例相比，“甘露案”的意义在于，其进一步明确了高等学校开除学籍处分决定的可诉性。最高人民法院在判决摘要中指出：“学生对高等院校作出的开除学籍等严重影响其受教育权利的决定可以依法提起诉讼。”^[3]在当前统一的高校行政诉讼案件司法解释无法出台的背景下，该案的判决要旨将有助于弥补高校行政诉讼领域中的规则之失局面。^[4]但是，与最高人民法院所出台的司法解释不同，《公报》案例并不具有强制下级法院适用的约束力，而仅仅是一种参照效力。对《公报》案例发布前后下级法院所作判决的对比研究表明，《公报》案例所宣示的判决要旨能否发挥出对下级法院的约束力，取决于判决本身在论理上是否具有实质的说服力。^[5]因此，对裁判理由及其内在说理品质的评判，是《公报》案例发挥个案指导力的必要前提。否则，其相比于司法解释在个案判断思路展示上的优势将无法发挥，甚至透过该案所提炼的一般规则也会随之丧失根基。

基于上述考虑，本文将对“甘露案”判决的论证理由作一番审视。在该案中，法官通过诉诸“立法原意”，限缩解释了“剽窃、抄袭他人研究成果”一词的规范内涵，并据此否定了暨南大学作出的开除学籍处分决定的合法性。我的分析将表明，由于法官跨越了法律解释方法适用的基本位阶，回避了历史解释方法在技术操作层面所面临的多重困境，混淆了著作权法和学术规范上判定剽窃行为应适用的不同标准，“甘露案”判决的推理过程是值得商榷的。而隐藏于判决理由背后、实际支配了法官整体判案思路的内在考虑，也无法经受起法解释学的进一步拷问。这预示着，“甘露案”难以作为一个有效的典型案例，为下级法院审理同类案件提供指导力。

二、直接诉诸立法原意？

《暨南大学学生管理暂行规定》第53条规定：“学生有下列情形之一，给予开除学籍处分：……

（五）剽窃、抄袭他人研究成果，情节严重的……”原《暨南大学学生违纪处分实施细则》第25条也作了类似的规定。为了明确甘露在结课论文中剽窃他人文章的行为是否落于上述条款的效力辐射范围之内，首先需要对“剽窃、抄袭他人研究成果”这一短语进行解释。对此，最高人民法院在判决书中直接指出：“暨南大学的上述规定系依据《普通高等学校学生管理规定》第54条第（5）项的规定制定，因此不能违背《普通高等学校学生管理规定》相应条文的立法本意。”[6]

正如判决文本所指出的，暨南大学在校纪校规中对学生剽窃行为的处分规定，系沿袭了教育部《普通高等学校学生管理规定》第54条第5项的规定。[7]因此，为了确定暨南大学校纪校规中规定的“剽窃、抄袭他人研究成果”的含义，需要对教育部的这一条款进行解释。对此，法官在判词中明确提出应根据“立法本意”来确定《普通高等学校学生管理规定》第54条第5项的规范内涵。这里的“立法本意”，应当理解为是立法机关在制定该法之时赋予这一条款的意思，即立法者在历史上所秉持的原意。据此，法官在此通过诉诸立法本意寻求“抄袭、剽窃他人研究成果”的规范内涵的方法，在法解释学上被称为历史解释方法（又称法意解释方法）。[8]

但是，法官在此运用的解释进路是值得商榷的。因为从法解释学上看，存在着文义解释、体系解释、历史解释、目的解释等多种解释方法，它们之间呈现出一定的适用次序。其中，文义解释是进行法律解释时应当首先考虑的方法。只有当文义解释不能得出唯一、确定的解释结论时，才能求诸其他方法。最高人民法院2004年发布的《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》即明确指出：“人民法院对于所适用的法律规范，一般按照其通常语义进行解释；有专业上的特殊涵义的，该涵义优先；语义不清楚或者有歧义的，可以根据上下文和立法宗旨、目的和原则等确定其涵义。”因此，在对《普通高等学校学生管理规定》第54条第5项的规定进行解释时，首先应当进行文义解释。而就该条款的规范表述来看，其并没有对行为人剽窃的方式作出特殊的限定。因此，从文义解释的角度来看，甘露在结课论文中剽窃他人论文的行为，完全可落于“剽窃、抄袭他人研究成果”这一短语的语义射程范围之内。

即使认为在本案中无法通过文义解释达成对“剽窃、抄袭他人研究成果”一词含义的清晰认定，也不应当就此径直采取诉诸立法原意的解释进路。因为在法解释学上，体系解释比历史解释居于更优先适用的地位。只有在通过体系解释仍然无法获致确切结论时，才能考虑适用历史解释、目的解释等方法。[9]体系解释要求解释者在确定某一条文的含义时，应考虑该部法律上下文相关条款的规定，或者

与这部法律相关的其他法律中类似条文的规定，从整体的角度把握其规范内涵。而作为与《普通高等学校学生管理规定》第54条第5项具有关联性的规定，教育部社会科学委员会2004年6月通过的《高等学校哲学社会科学研究学术规范（试行）》第2条和第9条明确规定，高校师生及相关人员在学术活动中不得以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果。因此，从保持法律规范体系一致性的角度来看，法官也不应当对《普通高等学校学生管理规定》第54条第5项“剽窃、抄袭他人研究成果”的方式加以特别限缩。

由上可见，无论是从文义解释还是从体系解释来看，均不宜对《普通高等学校学生管理规定》第54条第5项的“剽窃、抄袭他人研究成果”的方式加诸限定。法官在没有展开文义解释和体系解释作业的前提下便径直诉诸立法原意，将剽窃他人研究成果的方式限定于毕业论文、学位论文、公开发表的学术文章或著作、所承担科研课题的研究成果这几种情形之中，这在法律解释学上首先是值得商榷的。

三、历史解释的操作困境

退一步讲，即便不考虑法律解释方法的适用顺序，单就法官所运用的历史解释方法本身而言，也面临着诸多技术层面的操作困境。因为若要在判决中运用历史解释之方法，意味着法官必须令人信服地展示出存在着这种“立法本意”的论据。^[10]这些论据包括立法草案、审议记录、起草说明等。但在“甘露案”中，法官并没有承担起对这种立法资料的举证义务。寻遍判决书中的所有文字，并无任何可以支持立法原意的文献材料可循。

对此，我们或许会归咎于法官没有尽到判决说理的义务。但实际上，基于以下原因，法官要指明据以发现立法原意的文献资料，如果不是不可能的话，也是极为困难的。

其一，作为教育部制定的规章，《普通高等学校学生管理规定》在其制定过程中，并未如我国现行法律（狭义）那样，形成公开的立法草案说明。就当前中国规章制定的实际过程来看，其程序普遍缺乏透明性与规范性，制定过程中的各种意见常常不对外公开，甚至可能连制定机关自身也未形成完整的立法档案记录。^[11]在此背景下，要想获取用于证明该规章的立法原意的资料，显得至为困难。

其二，从立法的真实过程来看，法律文本常常是在历经多次妥协、交易，甚至是最后一刻的修改之后才制定出台的。有时，当对特定问题存有严重分歧时，为确保法案的顺利通过，立法文本中刻意使用了模棱两可或者具有高度涵盖力的语词。^[12]此时，由于不存在确定的立法者意志，通过诉诸立

法原意探求法条意旨的努力将会徒劳无功。在另外一些时候，最终形成的法律文本取决于个人的、任意的和反复无常的因素，例如法律起草者对特定用词的偏好，或者不经意间对特定语词的错误联想及偶然组合。**[13]**对于这些非常规性的信息，正式的立法资料则往往难以做完整的记录与呈现。

其三，即便在客观上存在着完整的立法资料，而且该资料完全向外界公开，要想在卷帙浩繁的立法资料中精确地定位并重现这种立法原意，也绝非易事。毕竟，法官作为法教义学的阐释者，并没有受过严格的历史研究训练，不能像法律史学家那样有能力和精力去还原立法者曾经的所思所想。**[14]**正是在此意义上，美国学者斯特劳斯教授断言，只有历史学家才有能力提炼立法原意，而律师和法官均难以胜任此项工作。**[15]**

其四，也是更为重要的，立法原意是指立法机关的意志，而非参与立法起草、审议工作的立法成员的意志或其汇总。作为一个组织体，立法机关并不像个人那样具有可供事后复述的记忆与表达装置，因而立法原意在很大程度上只是一种拟制的概念。事实上，寻求立法原意的解释，如果说不是一种徒劳的解释作业的话，也往往只是表达了解释者个人的意图、目的和理解，并借助“立法原意”这一概念背后隐含着的立法机关的权威，实现合法化的包装。**[16]**即便真的存在所谓的立法机关原意，唯一客观、有效的途径乃是以正式出台的立法文本为依据间接推断得出。**[17]**但这与其说是在还原立法者当时的历史原意，毋宁在于探求隐藏于成文法背后的客观含义。而作为对法条所蕴含的客观意旨的呈现，这种解释进路已经与借助立法史探求规范内涵的历史解释方法相距甚远。

除了借助立法资料寻求立法原意之外，在我国司法实践中，法院在遇到对立法原意没有把握或者产生分歧的情形时，还常常通过向立法机关提出询问的方式，寻求后者对立法原意的答复意见。**[18]**在“甘露案”审理过程中，最高人民法院也确实通过向教育部发函，征询了《普通高等学校学生管理规定》第54条第5项中的“剽窃、抄袭他人研究成果”的含义，并将该机关的解释结论视为“立法本意”。**[19]**但是，这种将原制定机关事后对法条的解释意见视为立法原意之再现的做法，更是值得质疑的。

首先，在司法实践中，作为支撑立法原意的历史材料，应当形成于立法文本通过之前。香港终审法院在“庄丰源案”判决中便指出，用以确定立法背景与立法目的的外来资料，一般而言应形成于立法文本颁布之前。**[20]**因此，法院通过发函的方式所获取的、由立法机关在法律制定之后所出具的法律解释结论，并不是适格的“历史”文献材料。

其次，这种事后获取的解释意见，由于缺乏客观化的约束机制，难以避免立法机关工作人员在解

释时的主观恣意。美国法院之所以在审判实践中倾向于拒绝接受立法成员在法律颁布之后提供的法律解释意见，其原因即在于此。[21]这种由立法机关或原立法起草人员在欠缺有效约束机制的情况下单方面作成解释结论的做法，是人治而非法治的反映与表现。[22]

最后，在理论上，用于证立立法原意的文献资料，必须已经向社会公开，否则便不能在判决书中援引。[23]而在判决过程中，法院与立法机关之间内部传递法律解释意见的做法，便欠缺这种公开性要素，违背了民众的预测可能性。因此，本案法官事后通过向教育部提出征询意见获取立法原意的做法，并不具有正当性。

在判决中运用历史解释的方法，无论是借助立法资料还是事后向立法机关征询意见，均反映出法官对立法者主观意志的依赖。这种解释立场，在法解释理论上属于“主观说”。从国外的情况来看，“主观说”并不占据主流地位。英国法院在长期的法律解释实践中，奉行不得参阅议会立法资料的信条。[24]这一信条建立在分权原则之上，即议会仅仅负责制定法律，而解释法律的工作应交由法院独立完成。虽然在1993年的“库珀诉哈特案”中，上议院改变了上述排除性规则，确立了法院在例外情况下可以参考议会议事录的规则及其适用条件。[25]但英国学界对该案的批评之声不绝于耳，其要点是质疑该案判决将议会陈述资料等同于议会意图的推论，同时认为它将对英国的宪政结构造成严重冲击，而且在要求律师寻找海量的议会资料方面会为其课加过重的负担。[26]2003年，上议院在其作出的“威尔森诉贸易及工业大臣案”判决中，充分吸收了学术界的上述讨论，对库珀案所确立的规则作出了修正，提出议会材料仅仅是法官解释法律的背景性资料，其本身并不能决定法律文本的含义。[27]在美国，最高法院沃伦大法官在1954年的“布朗诉教育委员会案”中，也明确拒绝通过参考美国宪法第14修正案的立法史来确定其规范内涵，直言这种解释进路并不具有说服力，由此推翻了该院在1896年的“普莱西案”（*Plessy v. Ferguson*）中所作的“隔离但平等”判决。[28]德国著名法哲学家拉德布鲁赫更是借助隐喻，认为法解释工作犹如轮船出海，虽一开始由领航者引导出港，但是在海上航行却完全交由船长指挥；同样的，法律制定之后，也应当交由解释者来决定其如何实施。[29]总而言之，在当前，注重法条客观内涵的“客观说”占据了通说地位。[30]而作为探求立法者主观意志的历史解释方法，其在运用过程中也不得不随着“主观说”的式微而逐渐淡出历史舞台。

四、剽窃含义的解读错位

鉴于获取立法原意的困难，或许更为合理的理解是，法官在判决书中所提示的“立法本意”，仅仅

是司法判词中的一种修辞，其目的在于赋予判决结论以权威性色彩，借以提升当事人接受判决结论的可能性。因此，法官接下来对“剽窃、抄袭他人研究成果”一词的规范内涵所作的具体解释，才是本案更为重要的问题。

对此，法官在判决书中是这样叙说的：

《普通高等学校学生管理规定》第五十四条第（五）项……所称的“剽窃、抄袭他人研究成果”，系指高等学校学生在毕业论文、学位论文或者公开发表的学术文章、著作，以及所承担科研课题的研究成果中，存在剽窃、抄袭他人研究成果的情形。……甘露作为在校研究生提交课程论文，属于课程考核的一种形式，即使其中存在抄袭行为，也不属于该项规定的情形。[31]

在此，依据行为所发生的载体的不同，法官特意区分了两类剽窃行为：一类是在毕业论文、学位论文、公开发表的作品、科研课题研究成果中实施的剽窃行为；另一类是在课程论文中实施的剽窃行为。法官认为，后者并不属于《普通高等学校学生管理规定》第54条所规定的剽窃行为。需要追问的是，这两类剽窃行为究竟有何种本质区别？法官据以作出这种区分的标准是什么？从判决书上所归纳的两种情形来看，法官是以作品是否向不特定的第三人公开作为认定剽窃行为是否成立的标准。因为无论是公开发表的学术文章、著作，还是毕业论文、学位论文或者所承担科研课题的研究成果，均属于向不特定的第三人公开的作品。与之相反，甘露的课程论文仅提交给任课教师，并没有向不特定的社会公众公开，这就与前述几种情形构成了显著区别。

在笔者看来，法官之所以作出上述区分，系受到了著作权法上判定剽窃侵权行为的标准的影响。

《著作权法》第47条明确规定，剽窃他人作品的，应当承担民事责任。关于如何认定著作权法上的剽窃行为，国家版权局版权管理司在1999年所作的一个答复中指出：“由于抄袭物须发表才产生侵权后果，即有损害的客观事实，所以通常在认定抄袭时都指经发表的抄袭物。”[32]结合《著作权法》第10条第1款第1项和《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条的规定，《著作权法》上的“发表”，是指作品向不特定的人公开。据此，如果剽窃物没有向不特定的人公开，就无法认定为著作权法上的剽窃行为。“甘露案”的法官便是基于上述著作权法上判定剽窃行为的规定，认为由于甘露的剽窃行为未向不特定的社会公众公开，因而无法将其认定为剽窃行为。

但是，将著作权法上认定剽窃行为的判断标准，径行迁移至对《普通高等学校学生管理规定》第54条第5项中的“剽窃、抄袭他人研究成果”一词的解释之上，是值得商榷的。法官在此忽视了著作权

法意义上的剽窃行为与学术剽窃行为在法律关系性质、侵害的法益、构成要件等方面所存在的重大差别。作为调整著作权人与剽窃行为人之间平等民事关系的法律，[著作权法](#)通过对剽窃行为的规制，旨在为著作权人针对作品所享有的人身权和财产权提供法律救济。该法规定的剽窃行为属于民事侵权行为，因此在判定剽窃行为是否成立之时，须以剽窃物已经向不特定人公开为要件，否则便无法认定著作权受到侵害的事实。与之相反，《普通高等学校学生管理规定》是调整高校与学生之间纵向管理关系的行政规章。该法所规制的剽窃行为属于学术不端行为，此类行为并非是侵害著作权人的人身权和财产权，而是损害了与剽窃者具有竞争关系的学术共同体成员的竞争利益，并破坏了剽窃作品的预期读者对剽窃者的信赖关系。^[33]因此，对学术剽窃行为的认定，不必像[著作权法](#)那样以剽窃作品的公之于众为前提，而重在判定其行为是否构成了对学术同行竞争关系的侵害和对作品受众信赖利益的辜负。在本案中，甘露在结课论文中实施的剽窃行为，便损害了一同选修该课程的其他同学在学习成绩评定上的竞争性利益，同时破坏了作为文章阅读者的任课教师对其的信任关系，为此应被认定为学术不端行为，而须受到该校相应的学术纪律处分。

在国外，也没有将剽窃作品的公之于众作为判定学术剽窃行为的要件。根据一种较为通行的定义，学术剽窃是指“使用他人的观点或文字，而不说明材料的来源”。^[34]其中，被剽窃的作品是否公之于众，并不构成对学术剽窃行为进行认定的影响因素。波斯纳法官就直言：“在复制作品未发表的情况下，同样可能构成剽窃，例如学生论文剽窃。”^[35]在此意义上，《高等学校哲学社会科学研究学术规范（试行）》中有关高校科研人员在学术活动中不得以任何方式进行剽窃的规定，也正是沿承了国际上的通行认定标准。

但在我国，混淆上述两种剽窃行为判定标准的观点，却并不在少数。例如，有学者在将剽窃行为定性为学术不端行为之后，便径直指出其触犯了[著作权法](#)的规定。^[36]上述分析表明，至少在剽窃作品是否需要以公之于众为要件这点上，学术规范意义上的剽窃与[著作权法](#)上所界定的内涵存在差异。^[37]事实上，在颇为瞩目的“王天成与周叶中等申请侵犯著作权纠纷再审案”中，最高人民法院已经隐约意识到了两种剽窃行为的内涵差异。该案判决虽然认定周叶中等的行为不构成[著作权法](#)上的剽窃侵权行为，但同时指出：“至于该相同或基本相同的文字部分的使用，是否构成学术规范意义的剽窃，以及仅以参考文献的方式使用他人思想表达是否符合学术引注规范，不属于[著作权法](#)调整的范畴，因此不属于本案的审理范围，本院不予评价。”^[38]在此背景下，最高人民法院在“甘露案”中，却将直

接将[著作权法](#)上判定剽窃的标准用于学术剽窃行为的判定，实在值得检讨与反思。

五、判决内在动因之省思

行文至此，本文对“甘露案”判决的分析，无论是基于法律解释方法运用的检讨，还是基于司法判决知识运用之反思，均是围绕判决书文本上所给出的裁判理由而展开。但从司法审判的实际运作过程来看，在很多时候，法官往往首先凭借司法直觉形成针对个案的看法，然后再去寻找证成这一先见的具体判决理由。此时，法官隐藏于判决书背后的真实意图，比在判决书文本中所展示的论证理由更为重要。因此值得探究的是，法官究竟是基于何种内在考虑作出了上述解释结论？对此，透过对判决书字里行间中所隐约呈现的判断思路的解读，并结合其他材料，我们至少可以捕捉到两点端倪。

其一，法官认为甘露在结课论文中进行剽窃的行为属于考试作弊行为，而非学术不端行为。“甘露案”判决这样提示道：

《普通高等学校学生管理规定》第五十四条列举了七种可以给予学生开除学籍处分的情形，其中第（四）项和第（五）项分别列举了因考试违纪可以开除学籍和因剽窃、抄袭他人研究成果可以开除学生学籍的情形，并对相应的违纪情节作了明确规定。其中第（五）项所称的“剽窃、抄袭他人研究成果”，系指高等学校学生在毕业论文、学位论文或者公开发表的学术文章、著作，以及所承担科研课题的研究成果中，存在剽窃、抄袭他人研究成果的情形。……甘露作为在校研究生提交课程论文，属于课程考核的一种形式，即使其中存在抄袭行为，也不属于该项规定的情形。[39]

从这段判词中可以解读出，法官是将提交课程论文这种考核方式定性为考试，进而认为甘露的行为属于考试作弊行为。[40]有关这一点，也可以得到本案主审法官的证实。耿宝建法官在事后对“甘露案”所撰写的评析意见中，便明确指出，甘露的行为“在本质上仍然是考试作弊，属于违反考试纪律的行为”。[41]据此，法官认为，暨南大学在对甘露作出处分决定时，应当援引有关考试违纪处分的规定，而非剽窃处分的规定。

其二，法官可能在情感上同情甘露的遭遇，认为暨南大学对其作出的开除学籍的处分过重。这可能是支配法官作出上述判断结论更为重要的内在动因。法官的下述判词，便隐约表达了这种立场：“在对违纪学生作出开除学籍等直接影响受教育权的处分时，应当坚持处分与教育相结合原则，做到育人为本、罚当其责，并使违纪学生得到公平对待。”[42]因此，为了否定暨南大学作出的开除学籍决定，法官采取了近似于釜底抽薪的方式，将甘露实施的课程论文剽窃行为，直接排除于“剽窃、抄袭

他人研究成果”一词的语义涵盖范围之外。

但在笔者看来，上述支配了法官整体判案思路的两点内在考虑，同样无法经受起法解释学上的进一步推敲。

第一，结合相关条款的规定来看，甘露的行为不应定性为考试违纪行为。《普通高等学校学生管理规定》第12条明确规定，考核分为考试和考查两种。从该条将“考试”和“考查”相并列的规定方式来看，此处的“考试”，其含义指的是狭义上的考场考试；而本案中以学生递交结课论文所进行的考核方式，应定性为“考查”。有关这一点，也可以在同法第54条中得到印证。该条规定：“学生有下列情形之一，学校可以给予开除学籍处分：……（四）由他人代替考试、替他人参加考试、组织作弊、使用通讯设备作弊及其他作弊行为严重的……”从这条文所使用的“替他人参加考试”“使用通讯设备”等语词的具体情境来看，其中的考试作弊行为，指的是考场中的作弊行为，而非本案甘露在提交课程论文中所发生的剽窃行为。因此，甘露在结课论文中实施的剽窃行为，并不属于该规章第54条第4项所规定的考试违纪行为。

第二，即便法官认为暨南大学的开除学籍处分决定过于严厉而欲否定该决定，也完全可以借助其他更具说服力的法解释技术予以实现。因为从《普通高等学校学生管理规定》第54条第5项的规范表述来看，对学生给予开除学籍处分，除构成剽窃、抄袭行为之外，还须满足该项后段所规定的“情节严重”的构成要件。因此，如果法官基于对甘露遭遇之同情，意欲排除开除学籍处分规定的适用，也完全可以透对“情节严重”一词的严格解释达成。虽然甘露因先后两次反复实施剽窃行为，其被排除于“情节严重”一词的语义辐射范围的可能性已有所缩减，但毕竟仍在法解释学上具有可争辩的语义空间。与本案判决中法官人为地限缩“剽窃、抄袭他人研究成果”一词的规范内涵的做法相比，借助对“情节严重”的限缩解释来确认处分决定的违法性，在论理上更具说服力。

六、结论

“甘露案”是最高人民法院审理的首个高校行政诉讼案件，它承载着司法界进一步统一高校行政诉讼案件审理规则的厚重期望。但是，作为《公报》典型案例，其功能不应仅停留于抽象性规则供给的层面之上。[43]相反，最高人民法院应当通过对“甘露案”判决论证理由和判断思路的详细展示，为下级法院审理类似案件提供可资借鉴的一个范本。这不仅是案例指导制度相比于抽象性司法解释的优势所在，也是从该案中所提炼出来的一般规则发生效力的前提条件。但遗憾的是，由于未遵循法律解释

方法运用的基本位阶，选取了面临着多重操作困境的历史解释方法，且混淆了**著作权法**上与学术规范上判定剽窃行为的不同标准，“甘露案”判决的论证理由难以令人信服。而隐藏于判决理由背后、实际支配了法官整体判案思路的内在考虑，也无法经受起法解释技术的进一步拷问。“甘露案”判决在论证说理过程中存在的上述瑕疵，预示着其难以作为一个适格的典型案例，为下级法院审理同类案件提供指导。

当前，案例指导制度正在司法实务界全面展开。但是，阅读这些指导性案例或典型案例后不难发现，当前案例指导制度运行的侧重点，在于归纳抽象性的规则，以期收到弥合法律织物的漏洞、统一法律适用尺度之效。与之相比，对个案论证理由与判断思路的展示，却因为属于更为微观层面的技术操作细节问题而时常被忽略。本文对“甘露案”判决论证瑕疵的剖析，希望能够引起司法系统对指导性案例或典型案例内在论理品质的重视。这不仅将有助于展示出案例指导制度相比于抽象性司法解释的“比较优势”，也是提升法官的说理水平、确保裁判文书质量的根本途径之所在。

【注释】

清华大学法学院宪法学与行政法学专业2012级博士生。余凌云教授、何海波教授、刘晗助理教授以及本刊匿名审稿专家对本文提出了重要的修改意见，在此谨致谢忱。

[1]参见余凌云：“法院如何发展行政法”，载《中国社会科学》2008年第1期。

[2] See Thomas E. Kellogg, “Courageous Explorers”? Education Litigation and Judicial Innovation in China, 20 Harv. Hum. Rts. J. 141, 143 (2007).

[3] “甘露不服暨南大学开除学籍决定案”，载《最高人民法院公报》2012年第7期。

[4] 最高人民法院在2004年前后即动议制定高校行政诉讼代理人司法解释。2010年，最高人民法院起草完成了《关于审理高等教育行政案件若干问题的规定（草案）》，并召开了多次研讨会，并征求了专家学者的意见。但迄今为止，该司法解释仍没有出台。相关报道，请参见席锋宇：“‘高校无讼’局面将改变”，载《法制日报》2004年8月11日第1版；申欣旺：“司法却步‘大学自治’？”，载《中国新闻周刊》2012年第12期。

[5]参见陈越峰：“公报案例对下级法院同类案件判决的客观影响——以规划行政许可侵犯相邻权争议案件为考察对象”，载《中国法学》2011年第5期；李友根：“指导性案例为何没有约束力——以

无名氏因交通事故致死案件中的原告资格为研究对象”，载《法制与社会发展》2010年第4期。

[6] 同前注3所引文，第38页。

[7]教育部《普通高等学校学生管理规定》第54条规定：“学生有下列情形之一，学校可以给予开除学籍处分：……（五）剽窃、抄袭他人研究成果，情节严重的……”

[8] 参见梁慧星：《民法解释学》，中国政法大学出版社1995年版，第219页。

[9] 参见[德]卡尔·拉伦茨：《法学方法论》，陈爱娥译，商务印书馆2004年版，第220页。

[10]参见强世功：“文本、结构与立法原意——‘人大释法’的法律技艺”，载《中国社会科学》2007年第5期。

[11]参见何海波：《行政诉讼法》，法律出版社2011年版，第83页。

[12]参见苏力：“解释的难题：对几种法律文本解释方法的追问”，载《中国社会科学》1997年第4期。

[13] See Max Radin, Statutory Interpretation, 43 Harv. L. Rev.863, 873 (1930) .

[14]恩吉施认为，在对待制定法的历史含义的问题上，要区分法律史学家与法律教义学者的不同角色，后者首先关注的是制定法本身的实质内容。参见[德]卡尔·恩吉施：《法律思维导论》，郑永流译，法律出版社2004年版，第104-106页。

[15] See David A. Strauss, The Living Constitution, Oxford University Press, 2010, p. 18.

[16]See Joseph P. Witherspoon, Administrative Discretion to Determine the Statutory Meaning,35 Tex. L. Rev.63,74-75 (1956) ; Antonin Scalia,A Matter of Interpretation, Princeton University Press,1997,pp.16-17.

[17]参见[美]杰里米·沃尔德伦著：《立法者的意图和无意图的立法》，张卓明等译，载[美]安德雷·马默主编：《法律与解释：法哲学论文集》，法律出版社2006年版，第442页。

[18]参见乔晓阳主编：《立法法讲话》，中国民主法制出版社2000年版，第194页。

[19]教育部法制办公室副主任王大泉证实了这一点。参见“‘甘某诉暨南大学案’学术研讨会会议记录”，载湛中乐主编：《教育行政诉讼理论与实务研究》，中国法制出版社2013年版，第417页。

[20] Director of Immigration v Chong Fung Yuen [2001]2 HKLRD 533.

[21] See Robert S. Summers, Statutory Interpretation in the United State, in D. Neil MacCormick and Robert S. Summers (eds.), *Interpreting Statutes: A Comparative Study*, Dartmouth Published Company Limited, 1991, pp.429-430.

[22] 参见张明楷：“立法解释的疑问”，载《清华法学》2007年第1期。

[23] 参见黄茂荣：《法学方法与现代民法》（第五版），法律出版社2007年版，第341页。

[24] 英国著名学者戴雪（A. V. Dicey）曾指出：“大凡一宗草案一经通过，即可受法院诠释；而每当诠释之际，法院惟以法案中之条文的原文为根据，至于两院中之一院所有在辩论中通过的任何决议，或在讨论中篡改的任何字句，审判员概不加以承认。”[英]戴雪：《英宪精义》，雷宾南译，中国法制出版社2001年版，第416页。

[25] 该案判决归纳了法院可以例外地参考议会资料的三个条件：（1）法条的字面含义模糊不清或者是荒谬的；（2）所参考的议会资料中，包含了由大臣或其他提案者所作的陈述；如有必要，还可以结合其他有助于理解这些陈述的议会资料；（3）前述陈述必须是清晰的。Pepper (Inspector of Taxes) v. Hart [1993] A. C.593.

[26] See Scott C. Styles, *The Rule of Parliament: Statutory Interpretation After Pepper v Hart*, (1994) 140. J. L. S.151; Jonan Steyn, *Pepper v Hart: A Re-examination*, (2001) 210. J. L. S.59; Aileen Kavanagh, *Pepper v Hart and Matters of Constitutional Principle*, (2005) 121 L.Q.R.98.

[27] *Wilson v. First County Trust Ltd (No.2)* [2003] UKHL40; [2004] 1 A. C.816 at 827.

[28] *Brown v. Board of Education of Topeka*, 347 U. S.483 (1954).

[29] 参见[德]古斯塔夫·拉德布鲁赫：《法哲学》，王朴译，法律出版社2006年版，第115页。

[30] 参见卡尔·恩吉施，同前注14所引书，第108页。

[31] 同前注3所引文，第38页。

[32] 《国家版权局版权管理司关于如何认定抄袭行为给青岛市版权局的答复》（权司[1999]第6号）。

[33] 参见[美]理查德·波斯纳：《论剽窃》，沈明译，北京大学出版社2010年版，第23页、第52

页。

[34][英]保罗·奥利弗：《学术道德学生读本》，金顶兵译，北京大学出版社2007年版，第153页。

[35]理查德·波斯纳，同前注33所引书，第125页。

[36]参见曹树基：“学术不端行为：概念及惩治”，载《社会科学论坛》2005年第3期。

[37]这种差异也预示着，单纯依靠著作权法和侵权法的规定，无法对学术规范意义上的剽窃行为进行有效治理，后者在很大程度上有赖于学术共同体内部规训机制的建立。参见方流芳：“学术剽窃和法律内外的对策”，载《中国法学》2006年第5期。

[38]最高人民法院（2009）民申字第161号民事裁定书。

[39]同前注3所引文，第38页。

[40]《普通高等学校学生管理规定》第12条规定，考核分为考试和考查两种。根据这一规定，本案判词中法官所用的“考核”一词，属于一个上位概念，其包含“考试”和“考查”两种情形。

[41]最高人民法院行政审判庭编：《中国行政审判案例》（第三卷），中国法制出版社2013年版，第63页。

[42]同前注3所引文，第37-38页。

[43]如果案例指导制度仅定位于揭示抽象性规则，那么其功能完全可以被抽象性司法解释所替代，甚至由于存在着对案例进行多样化解读的可能性，前者的明晰程度还不如后者。参见王晨光：“制度构建与技术创新——我国案例指导制度面临的挑战”，载《国家检察官学院学报》2012年第1期。

本案法律依据

中华人民共和国著作权法(2010修正) 第10条1款1项
中华人民共和国著作权法(2010修正) 第47条
最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第9条
中华人民共和国行政诉讼法
普通高等学校学生管理规定(2005)[失效] 第12条
普通高等学校学生管理规定(2005)[失效] 第54条1款4项
普通高等学校学生管理规定(2005)[失效] 第54条1款5项

同案由重要案例

国家知识产权局与潼关肉夹馍协会等商标行政裁决纠纷上诉案
某专利股份有限公司与国家知识产权局等发明专利权无效行政纠纷上诉案
康某公司与中华人民共和国国家知识产权局等专利行政管理行政裁决纠纷上诉案
贾某川与廊坊市市场监督管理局等专利行政管理行政裁决纠纷上诉案
最高人民法院发布9个知识产权保护典型案例之一：惠州市顺某科技有限公司与国家知识产权局、山东某酒业有限公司商标权撤销复审行政纠纷抗诉案
重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案例之八：李某甲诉某区教育委员会统筹安排入学案——规范性文件限制拥有其他自有产权住房的直管公房承租人子女入读该公房对口学校的规定合法

某研究公司等与中华人民共和国国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案
北京中科奥森科技有限公司与国家知识产权局等发明专利权无效行政纠纷案

更多

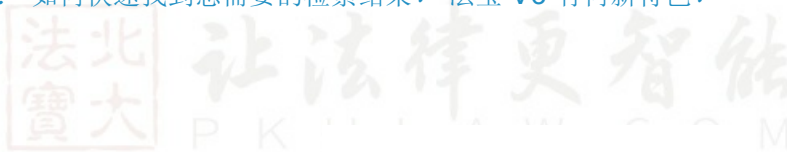
本法院同类案例

洛某有限公司、国家知识产权局等行政二审行政判决书
法国某某公司、某某知识产权局等发明专利权无效行政纠纷上诉案
福建某公司与国家知识产权局等外观设计专利权无效行政纠纷二审判决书
光某公司与国家知识产权局等专利行政管理行政裁决纠纷上诉案
蔡某颖与国家知识产权局等专利行政管理行政裁决纠纷上诉案
王某某与国家知识产权局等专利行政管理行政裁决纠纷上诉案
曾某某与国家知识产权局等专利行政管理行政裁决纠纷上诉案
某某有限公司与中华人民共和国国家知识产权局等专利行政管理行政裁决纠纷上诉案

更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/pfnl/c05aeed05a57db0a91a0f61d0f476848665018f4098ed332bdfb.html>